

1501182-31.2022.8.26.0048

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo Marzola Colombini

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... de ter praticado o réu o crime de tráfico de drogas.

Por tais motivos, dúvidas não restam quanto à configuração do crime de tráfico de drogas e da comprovação da autoria delitiva em relação ao acusado, impondo-se, por conseguinte, a sua condenação.

Reconhecida, assim, a autoria do crime de tráfico de drogas, entendo, todavia, restar caracterizada a causa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

3ª Vara Criminal

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia-SP - cep 12940-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501182-31.2022.8.26.0048 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501182-31.2022.8.26.0048

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2121154/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 24741081 -

DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 2121154 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EXPEDITO DONIZETE RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Marzola Colombini

VISTOS.

EXPEDITO DONIZETE RODRIGUES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e está sendo processado porque, no dia 04 de maio de 2022, no horário e local mencionados na denúncia, teria em depósito e teria guardado, para fins de tráfico, drogas, consistentes em 92 comprimidos de ecstasy (pesando, aproximadamente, 66 gramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado a fls. 129 e apresentou defesa preliminar às fls. 110/115.

A denúncia foi recebida às fls. 132/134.

Citado, em audiência de instrução e julgamento (fls. 203) foram ouvidas duas testemunhas arroladas exclusivamente pela Acusação, uma testemunha arrolada pela Acusação em comum com a Defesa, e uma testemunha arrolada exclusivamente pela Defesa, sendo, ao final, realizado o interrogatório do acusado, conforme gravações audiovisuais constantes dos autos.

Encerrada a instrução, o Ministério Público, em debates orais, requereu a integral procedência do pedido acusatório, para o fim de condenar o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, também em debates orais, requereu a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas (porte de drogas para consumo pessoal), tendo em vista sua condição de usuário de entorpecentes.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito previsto no art. 33, § 3º, da Lei de Drogas (cessão gratuita e eventual de drogas para consumo compartilhado). Subsidiariamente, ainda, postulou o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares a serem apreciadas.

No mérito, de rigor a integral procedência do pedido acusatório, para o fim de condenar o acusado pelo crime de tráfico de drogas, reconhecendo-se, contudo, a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), pelas razões abaixo mencionadas.

Com efeito, a materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 12/14, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 17/18, pelo documento de fls. 29 (print do aplicativo Whatsapp), pelo comprovante de depósito de fls. 56, pelo laudo pericial de exame químico toxicológico de fls. 103/105, bem como pela prova oral colhida em audiência.

A autoria, da mesma forma, restou certa e segura.

O réu Expedito Donizete Rodrigues, na fase policial (fls. 09/10), negou a prática delitativa, aduzindo que: não comercializa substâncias entorpecentes e nunca teve qualquer envolvimento com o crime; sempre trabalhou como comerciante; trabalhou na "Padaria do Marquinho" e no comércio "Maeda Hortifruti"; trabalha também como motorista de aplicativos "Uber" e "99"; possui alguns amigos que fazem uso de ecstasy; eles o pediram para comprar a substância entorpecente em São Paulo para que eles a usassem; aceitou o pedido por amizade; se dirigiu até a cidade de São Paulo e trouxe consigo os entorpecentes; não ganha qualquer valor pela venda da droga e somente ganha pelo transporte; não possui um amigo específico que lhe pede para trazer os entorpecentes; acaba fazendo isso para várias pessoas; cada uma delas lhe encomenda um determinado número de comprimidos; quando junta o pedido vai

até São Paulo para buscar os entorpecentes; não faz isso com frequência, mas apenas quando está na região de São Paulo; sempre vai até São Paulo com seu veículo Ford Ka; esses amigos residem em Atibaia; na data dos fatos, estava saindo de sua residência juntamente com seu patrão Marcos Vinicius, quando foi abordado por policiais civis; por ocasião da abordagem, estava saindo para trabalhar na empresa "Go Kids" que é de propriedade de Marcos Vinicius; não estava com nenhuma porção de entorpecente em seu poder; os policiais efetuaram buscas na sua residência e encontraram no armário da cozinha os comprimidos de ecstasy; ao que se recorda, em sua casa havia cerca de noventa comprimidos de ecstasy; na cidade de São Paulo, compra cada comprimido pelo valor de R\$ 35,00; cobra cerca de R\$ 180,00 por ida à cidade de São Paulo; não possui passagens criminais; nunca foi processado ou preso anteriormente aos fatos.

Em juízo, novamente negou a prática delitiva, aduzindo que: possui 36 anos de idade; trabalha como operador de máquinas e motorista; trabalhava como motorista do aplicativo Uber; é amasiado; não possui filhos; não possui antecedentes criminais; confirma a propriedade dos entorpecentes apreendidos; guardava as drogas em sua residência; adquiria os entorpecentes para seus amigos; possui um grupo de amigos; os entorpecentes são vendidos por um preço muito caro nas festas; como fazem o uso do ecstasy, preferem comprar juntos e dividir entre si para uso comum; distribui os entorpecentes entre 04 casais, além de guardar certa quantia para consumo próprio; pagou pelo entorpecente a quantia de R\$ 135,00 por comprimido de ecstasy; comprava o total de entorpecentes e pagava com seu dinheiro; após, encontrava o grupo de amigos e lhes entregava a parte deles; frequenta a casa desses amigos e participam de festas de música eletrônica juntos; eles rateavam entre si o dinheiro referente ao custo do transporte das drogas; já havia comprado os entorpecentes em outras duas ocasiões; os R\$ 600,00 reais apreendidos foram sacados para pagamento de seu aluguel; o proprietário do imóvel não possui conta bancária, razão pela qual efetua o pagamento em dinheiro; a balança grande, branca, era destinada à pesagem de alimentos; a balança de precisão apreendida era utilizada para a pesagem de glutamina e creatina que consome pela manhã, por indicação de nutricionista, tendo em vista que frequenta academia; as balanças não são utilizadas para embalar entorpecentes; as embalagens apreendidas eram utilizadas para embalar alimentos, como glutamina e creatina; adquiria os entorpecentes próximo da cidade de Guarulhos; dirigia até lá com seu veículo Ford Ka; não havia entorpecentes no porta-malas de seu veículo; não haveria necessidade de armazená-los em seu porta-malas, devido ao tamanho dos comprimidos; na ocasião dos fatos, Marcus Vinicius havia chegado com seu veículo; na semana anterior, havia realizado uma viagem com seus amigos, onde alugaram uma casa e fizeram um passeio de lancha juntos; não confessou informalmente aos policiais que praticava a venda de entorpecentes; nunca ofereceu entorpecentes a pessoas fora de seu círculo de amizades; é uma pessoa honesta e trabalhadora; não bebe nem fuma; parou de fazer uso de ecstasy; na época dos fatos, fazia uso de ecstasy porque frequentava academia e evitava ingerir bebidas alcoólicas; atualmente, é registrado em sua empresa e recebe a quantia de R\$ 3.000,00; está arrependido dos fatos; cometeu um erro; não quer passar por isso nunca mais; excluíram o grupo de WhatsApp; perdeu amizades por conta dos fatos; foi um erro grave que o abalou e a todos os amigos do grupo.

Tal versão, no entanto, não restou integralmente comprovada, não merecendo, pois, a devida credibilidade pelo Juízo.

Isto porque o investigador de policial civil André Stopa Rankin, em juízo, relatou que: na data dos fatos, receberam denúncia anônima de que um indivíduo estava realizando tráfico de entorpecentes do tipo "ecstasy", utilizando-se de um veículo Ford Ka; realizaram campanha no local e observaram movimentações suspeitas do veículo; visualizaram ele descendo do veículo entrando e saindo do imóvel e retornando ao veículo diversas vezes; encaminharam relatório à autoridade policial que representou pelo mandado de pedido de busca a apreensão no imóvel do acusado; em cumprimento do mandado de busca e apreensão, abordaram o acusado e outro

indivíduo na porta do imóvel; realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado; ao adentrarem o imóvel, questionaram ao acusado se havia entorpecentes no local; primeiramente, ele negou a existência de entorpecentes no local; após apresentarem o mandado de busca e apreensão, ele confirmou que havia entorpecentes na residência e informou onde estavam localizados; no armário do acusado, localizaram cerca de 80 comprimidos da substância do tipo "ecstasy"; o colega dele afirmou que estava trabalhando com o acusado a pouco tempo e que não possuía ciência de que havia entorpecentes no imóvel; na residência, foram apreendidas, ainda, duas balanças e diversas embalagens plásticas pequenas; algumas das embalagens aparentavam já ter sido utilizadas para guardar comprimidos; também foram apreendidos um celular e a quantia de R\$ 600,00 em cédulas; realizada busca no veículo do acusado, encontraram, em uma blusa, no porta-malas, cerca de 06 comprimidos do mesmo entorpecentes; os comprimidos não estavam embalados; os comprimidos foram encontrados após sacudir a blusa; não sabe se os entorpecentes estavam no bolso da blusa; as drogas encontradas dentro do veículo eram idênticas aquelas encontradas na residência do acusado; na delegacia, Marcus afirmou que havia empregado o acusado recentemente e confirmou que ele comprava do acusado entorpecentes, bem como que ele já havia o entregue entorpecentes por algumas ocasiões; ele apresentou comprovante de pagamento do entorpecente em seu celular; ele informou que utilizavam o código "vitamina" ao efetuar a transação via pix; no interrogatório realizado na delegacia, ele negou a prática do tráfico de entorpecentes e afirmou que apenas buscava os entorpecentes para si e para seus amigos na cidade de São Paulo; ele disse que os entorpecentes encontrados no veículo pertenciam a uma pessoa a qual havia dado carona, porém não tinha ciência de que os comprimidos estavam lá; ele disse que as movimentações observadas em seu veículo eram de amigos; o acusado não ofereceu resistência à entrada na residência; ele foi educado e autorizou a entrada; não flagraram a venda de entorpecentes no local; não conhecia o acusado anteriormente aos fatos.

Nesse mesmo sentido, o investigador de polícia civil Cristiano Ramos de Oliveira, em juízo, narrou que: na data dos fatos, receberam denúncia anônima de que um indivíduo estava realizando tráfico de drogas sintéticas, bem como que as drogas estavam armazenadas no interior da residência do acusado; realizaram campana no local e observaram movimentações suspeitas no local; não observaram a venda de entorpecentes; encaminharam relatório à autoridade policial que representou pelo mandado de pedido de busca a apreensão no imóvel do acusado; em cumprimento do mandado de busca e apreensão, abordaram o acusado e outro indivíduo saindo da residência; em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado; após cientificar o acusado do mandado de busca e apreensão, ingressaram no imóvel; o acusado informou que os comprimidos de ecstasy estavam armazenados no armário da cozinha; no referido armário, encontraram os comprimidos; também apreenderam duas balanças de precisão e diversas embalagens, além da quantia de R\$ 600,00; no interior do porta-malas do veículo, entraram outros 06 comprimidos idênticos aqueles encontrados no interior da residência; o veículo estava estacionado em via pública; o acusado confirmou que adquiria os entorpecentes da cidade de São Paulo e revendia aos seus amigos e outros clientes; o outro indivíduo que estava no local afirmou que trabalhava em uma empresa de máquinas e que havia contratado o acusado como seu empregado; ele disse que fazia uso de ecstasy e já havia adquirido os entorpecentes do acusado; o acusado colaborou com a abordagem e não apresentou resistência; não conhecia o acusado anteriormente aos fatos.

A testemunha Marcos Vinicius Pereira Chiment, arrolada pela Acusação em comum com a Defesa, ouvida como informante por ser amigo íntimo do réu, em juízo, afirmou que: o acusado trabalha em sua empresa "Go Kids"; são amigos próximos; ele é um ótimo amigo e trabalha muito bem na empresa; pretende promovê-lo a gerente; frequentam a casa um do outro e realizam viagens juntos; quando os policiais civis os abordaram, estava na residência a fim de levar ferramentas de trabalho ao acusado; quando tocou a campainha, a polícia os abordou; acompanhou as buscas no interior da residência; os entorpecentes encontrados na residência eram para uso comum com o

acusado; fariam uso das substâncias em uma viagem para Capitólio/MG; a polícia localizou cerca de 88 comprimidos de ecstasy; costumam frequentar festas juntos e consumir os entorpecentes; possuem um grupo de amigos de cinco casais; ele comprou os entorpecentes para fazerem uso em comum; suas esposas não ingerem bebidas alcoólicas porque frequentam academia; costumavam dividir entre si as drogas; usavam as drogas com certa frequência em churrascos e festas eletrônica; evitam o consumo de bebidas alcoólica e preferem consumir "bala"; o acusado sempre frequentou academia; a balança era usada para pesar a comida porque fazia dieta; ele adquiria as drogas próximo da cidade de Guarulhos; ele não vendia drogas; ele apenas dividia as drogas entre os amigos; pagava entre R\$ 30,00 e R\$ 60,00 por comprimido; o acusado não lucrava com isso; pagavam pelo preço de custo dos comprimidos; utilizavam o código de "vitamina" ao se referirem ao "ecstasy".

Por fim, a testemunha Fernando Adriano Lopes, arrolada exclusivamente pela Defesa, em juízo, narrou que: é usuário da substância "ecstasy"; soube que a polícia localizou 90 comprimidos do entorpecente; uma parte dos comprimidos apreendidos lhe pertenciam; iriam dividir os entorpecentes entre si; o acusado comprava as drogas com seu próprio dinheiro; posteriormente, ele iria informar quanto pagou pela droga e iriam dividir os valores e os entorpecentes entre si; iria encontrar com ele em uma festa no final de semana; possuem um grupo de amigos que costumam sair juntos; conhece o Marcus Vinicius e a esposa dele, além de outros casais; a quantia foi encomendada pelo grupo a ele.

Neste contexto, dúvidas não restam acerca da caracterização do crime de tráfico de drogas imputado ao acusado, pelos seguintes motivos: I - apreensão de relativa quantidade de entorpecentes (92 porções de ecstasy), além de duas balanças de precisão e 100 embalagens (sacos plásticos); II - confissão informal do acusado aos policiais civis no momento da abordagem; III - depoimentos harmônicos e coesos dos policiais civis responsáveis pela abordagem e prisão do réu; IV - apreensão de significativa quantia em dinheiro em poder do réu (R\$ 600,00), sem comprovação de origem lícita.

Com efeito, os policiais civis André e Cristiano, tanto em solo policial quanto em juízo, apresentaram depoimentos coesos e verossímeis, confirmando que, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, apreenderam no imóvel do acusado mais de 80 comprimidos de ecstasy, além de duas balanças de precisão, embalagens e a quantia de R\$ 600,00 em cédulas.

Aduziram, também, que, em revista ao veículo do acusado, encontraram, no porta-malas, outros 06 comprimidos de ecstasy, idênticos àqueles encontrados no interior da residência do acusado, totalizando 92 porções do entorpecente.

Como se não bastasse, narraram que o réu no momento da abordagem confessou informalmente que os entorpecentes apreendidos lhe pertenciam, bem como os adquiria na cidade de São Paulo e revendia aos seus amigos e conhecidos.

Tal versão dos policiais civis restou em consonância com a maior parte das provas carreadas aos autos, motivo pelo qual merece credibilidade por este Julgador.

Outrossim, insta ressaltar que não há falar em ausência de credibilidade no relato de servidores policiais na medida em que, na condição de testemunhas, suas palavras ostentam o mesmo valor probatório que o de qualquer outra, não se podendo retirar a boa-fé pelo só fato de serem agentes de segurança. Nesse sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse

servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar, tal como ocorreu com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC nº 74.608-0-SP, rel. Min. Celso de Mello).

Na verdade, o testemunho de servidores policiais merece fé até prova em contrário (RT 426/439), desde que não fique demonstrada a sua inidoneidade (RT 444/406), ou o seu propósito deliberado de incriminar falsamente o réu (RT 454/422), o que não se verificou na hipótese dos autos, até mesmo porque os policiais civis sequer conheciam o acusado anteriormente aos fatos.

A versão do acusado, por outro lado, não restou integralmente comprovada, na medida em que sua condição de usuário não restou devidamente comprovada, além da alegação de que fornecia os entorpecentes de forma gratuita e eventual, para consumo compartilhado, com as pessoas de seu relacionamento.

Nesse ponto, afasto a tese da Defesa de desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06 (porte de drogas para consumo pessoal), uma vez que não há nos autos mínimos elementos indicativos da condição de mero usuário do acusado, sendo que, mesmo que assim não fosse, sua eventual condição de usuário não tem o condão de afastar a de traficante, consoante pacífica jurisprudência. Ao contrário, o conjunto probatório constante dos autos permite a perfeita caracterização do delito previsto no artigo 33, caput, do referido diploma legal.

No tocante à cessão gratuita e eventual de drogas para consumo compartilhado, incabível o acatamento do pleito da Defesa da desclassificação da conduta para aquela estabelecida no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 (cessão gratuita e eventual de drogas para consumo compartilhado), haja vista que não restou caracterizada nos autos a conduta incriminadora do tipo penal em questão, qual seja, “oferecer”, que, conforme ensina Renato Brasileiro de Lima (in “Legislação Criminal Especial Comentada”, 3ª edição, Editora JusPODIVM, 2015, p. 759), “significa ofertar como presente, sem a intenção de venda, ou seja, de forma gratuita”.

Neste particular, segundo leciona Fernando Capez, em seu Curso de Direito Penal, Volume 04, Legislação Penal Especial, 13a ed., 2018, São Paulo, Ed. Saraiva, pág. 548: “(...) a Lei n. 11.343/2006 passou a tipificar a conduta de oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem. Portanto, são seus requisitos: OFERECER DROGA + EVENTUALMENTE + SEM OBJETIVO DE LUCRO + A PESSOA DE SEU RELACIONAMENTO + PARA JUNTOS A CONSUMIREM”.

Nesse passo, no caso concreto, a desclassificação é inviável pela ausência dos requisitos legais.

Isto porque, no presente caso, o acusado, em juízo, nada mencionou a respeito de eventual oferta de entorpecentes aos supostos casais de amigos, dentre eles as testemunhas Fernando e Marcus (este ouvido na condição de informante), tendo alegado que adquiriu as porções de ecstasy a pedido destes, sendo que, posteriormente, ressarciriam o valor despendido na aquisição dos entorpecentes, além dos custos referentes ao transporte das drogas. Em outras palavras, in casu, não há que se falar em oferta gratuita de entorpecente, motivo pelo qual se revela de rigor a rejeição da tese Defensiva.

Destaco, nesse ponto, as evidentes contradições nas versões apresentadas pelo acusado em solo policial e em juízo. Isto porque, no interrogatório realizado na fase policial (fls. 09/10), o acusado foi categórico ao afirmar que “não possuía um amigo específico que lhe pedia para trazer os entorpecentes”, bem como que fornecia os entorpecentes para “várias pessoas” e, ainda, que cobrava pelo transporte dos entorpecentes.

Já em juízo, o acusado trouxe versão diversa e inovadora, no sentido de que apenas fornecia as drogas para pessoas de seu relacionamento, especificando tratar-se de cerca de cinco casais de amigos.

Cumprе destacar, outrossim, com relação à testemunha Fernando, que não há comprovação de se tratar de pessoa “de seu relacionamento”, tal qual disposta na Lei de Drogas.

Neste ponto, observo que Fernando foi categórico ao afirmar que não possui relação íntima com o acusado, tratando-se de mero conhecido, o qual fornecia os entorpecentes para consumo em festas eletrônicas. Restou evidenciado, portanto, que tal não fazia parte do núcleo de amizade próximo do réu.

Ademais, a Defesa não comprovou a utilização de toda a quantidade dos entorpecentes apreendidos para os referidos casais de amigos, não havendo como justificar a propriedade de tamanha quantia para consumo eventual apenas entre eles. Documentalmente, aliás, cf. print de fls. 29, só existe a compra, por parte da testemunha Marcus Vinicius, em 07 de abril de 2022, de entorpecente no valor de R\$ 60,00 (sessenta reais).

Ao contrário, a destinação para o tráfico ficou evidenciada pela quantidade (92 comprimidos), suficiente para entrega a dezenas de usuários/dependentes, normalmente em festas eletrônicas.

Levo em consideração, ainda, o fato de que o acusado afirmou, tanto em solo policial como em juízo, que adquiriu os entorpecentes a fim de revendê-los aos casais de amigos por pelo menos outras duas ocasiões (03, no total, portanto), afastando-se, portanto, a eventualidade da prática delitiva.

No sentido do exposto, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do estado de São Paulo é pacífica:

“Tráfico de entorpecentes – Agente que traz consigo 128,4 gramas de maconha e 7,7 gramas de “ecstasy” – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Alegação do agente no sentido de cessão gratuita a terceiros incompatível com a quantidade de entorpecente apreendida – Desclassificação para o art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/06 afastada. Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de “trazer consigo”. A procedência da alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas para cessão gratuita a terceiros deve ser aferida em consonância com a conjuntura de sua apreensão, devendo ser afastada se não se coadunar com a dinâmica dos fatos.” [...] (TJ-SP - APL: 00023982320178260066 SP 0002398-23.2017.8.26.0066, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 08/11/2018, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/11/2018)

“Apelação – Tráfico de drogas – Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – [...]. Defesa de A. busca a desclassificação delitiva para os crimes de cessão gratuita e eventual de drogas para consumo compartilhado ou de posse para consumo pessoal – Impossibilidade – Traficância caracterizada – Materialidade e autoria comprovadas – Prova oral e laudos periciais incriminadores – Pedido não atendido. Recursos da acusação e defesa não providos.” (TJ-SP - APR: 15001487920218260622 SP 1500148-79.2021.8.26.0622, Relator: Reinaldo Cintra, Data de Julgamento: 19/08/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/08/2022)

Observo, ainda, que, embora o réu tivesse alegado, em juízo, que o dinheiro encontrado em seu poder (R\$ 600,00) não era proveniente do tráfico, não houve

comprovação de tal alegação nos autos, ônus da prova que, a toda evidência, lhe competia (art. 156, do Código de Processo Penal).

Isto porque o réu sequer arrolou o suposto locador do imóvel como testemunha para confirmar a sua versão, em que pese ter afirmado que pagava o aluguel em espécie, tendo em vista que o proprietário não possuía conta bancária.

Ademais, cumpre registrar que também não merece ser levada em consideração a afirmação feita pelo réu, em juízo, no sentido de que os entorpecentes encontrados no interior de seu veículo (06 comprimidos) não lhe pertenciam.

Isto porque, além de os policiais civis terem apresentado depoimentos coesos no sentido de que os entorpecentes possuíam características idênticas àqueles encontrados na residência do acusado, não há nos autos qualquer menção a quem seria o verdadeiro proprietário de tais comprimidos de ecstasy, bem como justificativa plausível para que estivessem guardados no porta-malas de seu próprio veículo.

Levo em consideração, finalmente, a apreensão de duas balanças de precisão e 100 sacos plásticos (embalagens). Neste ponto, saliento que, apesar de o acusado ter afirmado, em juízo, que tais eram utilizadas para pesagem e armazenamento de alimentos, a Defesa não logrou comprovar tal alegação nos autos, ônus da prova que, a toda evidência, também lhe competia.

Em se tratando de crime de tipo misto alternativo, sendo suficiente a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, e uma vez afastada a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal e também a figura prevista no art. 33, § 3º, da referida lei (cessão gratuita e eventual a amigos), inegável a consideração de ter praticado o réu o crime de tráfico de drogas.

Por tais motivos, dúvidas não restam quanto à configuração do crime de tráfico de drogas e da comprovação da autoria delitiva em relação ao acusado, impondo-se, por conseguinte, a sua condenação.

Reconhecida, assim, a autoria do crime de tráfico de drogas, entendo, todavia, restar caracterizada a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei em questão, pois presentes todos os seus requisitos: o acusado é primário e portador de bons antecedentes, além de não existir prova de que ele se dedicasse a atividades criminosas (apesar de o acusado ter afirmado que praticou o delito por três ocasiões, no total), ou que integrasse organização criminosa. Razoável se mostra, portanto, a diminuição da pena a ele imposta na fração de 1/5.

Uma vez reconhecida a impossibilidade de se levar em consideração, na dosimetria da pena, em duplicidade, os critérios constantes do art. 42, da Lei de Drogas (quantidade e espécies de entorpecentes), sob pena de evidente "bis in idem" (cf. decidido pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, HCs 112.776/MS, 109.193/MG e 119.976, sendo este último publicado em 18/03/2014, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma), de se consignar que este Juízo os considerará apenas na definição da fração prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

Desta forma, no que se refere ao tráfico privilegiado, a fração acima mencionada tem por fundamento a elevada quantidade de droga apreendida (92 comprimidos de ecstasy), bem como a sua natureza (alto grau de nocividade). Ademais, decidiu o C. Supremo Tribunal Federal que o critério de redução previsto no § 4º é discricionário do Magistrado, por ocasião do julgamento do HC 111.668, Relator Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, julgado em 20 de março de 2012, nos seguintes termos:

"... o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista para a

concessão de tal benefício, tendo plena liberdade para aplicar a redução no patamar que considerar necessário e suficiente para reprovar e coibir o crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto. Do contrário, seria inócua a previsão legal de um patamar mínimo e um máximo.”

Da mesma forma, ensina Renato Brasileiro de Lima (“Legislação Criminal Especial Anotada”, 2ª edição, Editora Jus Podivm, 2014, p. 747) que: “Para fins de determinar o quantum de diminuição da pena, o juiz deve se valer dos critérios constantes do art. 42 da Lei de Drogas – natureza e quantidade da droga, personalidade e conduta social do agente –, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, desde que o faça de maneira fundamentada”.

Outrossim, uma vez reconhecida a impossibilidade de se levar em consideração, na dosimetria da pena, em duplicidade, os critérios constantes do art. 42, da Lei de Drogas (quantidade e espécie de entorpecentes), sob pena de evidente bis in idem (cf. decidido pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, HCs 112.776/MS, 109.193/MG e 119.976, sendo este último publicado em 18/03/2014, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma), consoante acima mencionado, de se consignar que este Juízo os considerará na definição da fração prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), sendo que, na 1ª fase da dosimetria, observará as demais circunstâncias judiciais (art. 59, do Código Penal), em especial as condições pessoais do agente (personalidade e conduta social) e as circunstâncias do crime.

Destarte, revela-se medida de rigor a condenação do acusado pela prática do delito de tráfico de drogas, reconhecendo-se, contudo, a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

Por fim, com relação veículo Ford Ka, placas PPL-1E75, cor branca, ano fabricação/modelo 2016, constato a necessidade de decretação de sua perda, nos termos do quanto disposto nos artigos 62 e 63, ambos da Lei nº 11.343/06.

Isto porque, em que pese o acusado, em juízo, ter afirmado que utilizou o veículo por apenas três ocasiões para o transporte dos entorpecentes, o C. Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 647 da repercussão geral (RE 638491, Rel. Min. Luiz Fuz, Plenário, julgado em 17 de maio de 2017, publicado em 23 de agosto de 2017), firmou a seguinte tese: “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.

Portanto, considerando a decisão supramencionada, do C. Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, vale frisar, revela-se medida de rigor a decretação da perda do veículo utilizado pelo acusado para transporte dos entorpecentes.

No sentido do exposto:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 647 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO APREENDIDO COM O SUJEITO ATIVO DO CRIME. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXIGÊNCIA DE HABITUALIDADE DO USO DO BEM NA PRÁTICA CRIMINOSA OU ADULTERAÇÃO PARA DIFICULTAR A DESCOBERTA DO LOCAL DE ACONDICIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. O confisco de bens pelo Estado encerra uma restrição ao direito fundamental de propriedade, insculpido na própria Constituição Federal que o garante (art. 5º, caput, e XXII). 2. O confisco de bens utilizados para fins de tráfico de drogas, à semelhança das demais restrições aos direitos fundamentais expressamente previstas

na Constituição Federal, deve conformar-se com a literalidade do texto constitucional, vedada a adstrição de seu alcance por requisitos outros que não os estabelecidos no artigo 243, parágrafo único, da Constituição. 3. O confisco no direito comparado é instituto de grande aplicabilidade nos delitos de repercussão econômica, sob o viés de que “o crime não deve compensar”, perspectiva adotada não só pelo constituinte brasileiro, mas também pela República Federativa do Brasil que internalizou diversos diplomas internacionais que visam reprimir severamente o tráfico de drogas. 4. O tráfico de drogas é reprimido pelo Estado brasileiro, através de modelo jurídico-político, em consonância com os diplomas internacionais firmados. 5. Os preceitos constitucionais sobre o tráfico de drogas e o respectivo confisco de bens constituem parte dos mandados de criminalização previstos pelo Poder Constituinte originário a exigir uma atuação enérgica do Estado sobre o tema, sob pena de o ordenamento jurídico brasileiro incorrer em proteção deficiente dos direitos fundamentais. Precedente: HC 104410, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06/03/2012, DJ 26-03-2012. 6. O confisco previsto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal deve ser interpretado à luz dos princípios da unidade e da supremacia da Constituição, atentando à linguagem natural prevista no seu texto. Precedente: RE 543974, Relator(a): Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, DJ 28-05-2009. 7. O Supremo Tribunal Federal sedimentou que: AGRADO DE INSTRUMENTO - EFICÁCIA SUSPENSIVA ATIVA - TRÁFICO DE DROGAS - APREENSÃO E CONFISCO DE BEM UTILIZADO - ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Impõe-se o empréstimo de eficácia suspensiva ativa a agravo, suspendendo-se acórdão impugnado mediante extraordinário a que visa imprimir trânsito, quando o pronunciamento judicial revele distinção, não contemplada na Constituição Federal, consubstanciada na exigência de utilização constante e habitual de bem em tráfico de droga, para chegar-se à apreensão e confisco - artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (AC 82-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 3-2-2004, Primeira Turma, DJ de 28-5-2004). 8. A habitualidade do uso do bem na prática criminosa ou sua adulteração para dificultar a descoberta do local de acondicionamento, in casu, da droga, não é pressuposto para o confisco de bens, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 9. Tese: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 10. Recurso Extraordinário a que se dá provimento.” (STF, RE 638.491 – PR, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Julgado em 17/05/2017, DJe 23/08/2017).

Verificadas, assim, autoria e materialidade delitivas, passo, pois, à fixação da pena a ser imposta ao acusado.

Na dosagem da pena-base, verifico que o dolo e as demais circunstâncias do crime permaneceram na previsibilidade do tipo legal e nada tiveram de excepcional que autorizassem a exasperação da reprimenda, observando-se que a quantidade e natureza das drogas foram consideradas apenas na fixação da fração do tráfico privilegiado (3ª fase). Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes. Não houve confissão (o acusado confessou apenas a propriedade das drogas encontradas em sua residência, negou a propriedade das drogas encontradas em seu veículo e alegou, contudo, que se destinavam ao seu próprio consumo e à cessão gratuita e eventual a amigos para consumo compartilhado). No mais, destaco que o acusado é primário, cf. pesquisa SIVEC de fls. 38/39 e certidão de fls. 40.

Finalmente, na terceira fase, em virtude da incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico

privilegiado), diminuo a pena de 1/5, pelas razões anteriormente apresentadas, totalizando 04 anos de reclusão, e 400 dias-multa.

Torno definitiva a pena acima fixada.

O dia-multa será fixado em seu mínimo legal, ante a ausência de informações específicas acerca da situação financeira do acusado, salvo aquela genericamente mencionada por ocasião de seu interrogatório judicial, insuficiente para tal finalidade.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, fixo, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, o aberto, tendo em vista a primariedade do acusado e a quantidade de pena fixada, não superior a 4 anos.

Ainda, em caráter excepcional, entendo presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal, razão pela qual converto a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade (observando-se o artigo 46, § 3º, do Código Penal) e prestação pecuniária, no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos, a ser destinado a uma entidade pública ou privada com destinação social.

Consigno que a fixação de duas penas restritivas de direitos - ao invés de uma pena restritiva e multa - tem por fundamento a gravidade em concreto da conduta delitiva do réu, além da quantidade de pena de prisão, bastante superior a 1 ano. Além disso, o valor a título de prestação pecuniária tem por fundamento a gravidade em concreto, além da situação financeira do acusado (ocupação, veículo, renda por ele mencionada em seu interrogatório, etc).

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que respondeu ao feito nessa condição, estando ausentes, ainda, os requisitos na prisão preventiva.

No mais, por entender desnecessárias no caso concreto, revogo as medidas cautelares fixadas às fls. 46/48 (art. 319, incisos I e V, do Código de Processo Penal).

ANTE O EXPOSTO, julgo integralmente PROCEDENTE o pedido acusatório constante da ação penal proposta pelo Ministério Público contra EXPEDITO DONIZETE RODRIGUES e assim o faço para CONDENÁ-LO como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 04 anos de reclusão, e 400 dias-multa, calculada a fração do dia-multa no trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção desde a sua ocorrência, em regime inicial aberto, convertida a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em local a ser fixado pelo Juízo da Execução, na forma do artigo 46, § 3º, do Código Penal, e prestação pecuniária, no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos, a ser destinado a uma entidade pública ou privada com destinação social, também a ser designada pelo Juízo da Execução, e com o direito de apelar em liberdade.

Destaco, ainda, a revogação, nesta oportunidade, das medidas cautelares fixadas às fls. 46/48 (art. 319, incisos I e V, do Código de Processo Penal).

Com o trânsito em julgado:

I) lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral para os fins previstos no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos);

II) oficie-se ao FUNAD com relação ao veículo apreendido às fls. 15/16, cuja perda restou decretada, pelas razões acima discorridas, bem como com relação ao numerário depositado a fls. 56 (R\$ 600,00), cuja perda ora decreto, tendo em vista a não

comprovação de sua origem lícita; e

III) oficie-se ao Setor de Armas e Objetos local para que promova a devida destinação com relação aos demais objetos apreendidos às fls. 15/16, ou, se o caso, à Central de Custódia do Instituto de Criminalística de Bragança Paulista.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, em seu mínimo legal (Lei Estadual de Custas), pois se encontra assistido por Defensor constituído (Procuração de fls. 54 dos autos em apenso), presumindo-se, assim, relativa capacidade econômica para arcar com tal despesa. Não houve, além disso, juntada de qualquer documento indicativo da sua miserabilidade, como, por exemplo, declaração de imposto de renda, certidão imobiliária, carteira de trabalho ou certidão da Ciretran.

P.I.C.

LEONARDO MARZOLA COLOMBINI
- Juiz de Direito -

Atibaia, 12 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA